

1015581-79.2022.8.26.0224

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Magistrado: Lincoln Antônio Andrade de Moura

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 10ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... de localizar o veículo, em caso de roubo ou furto, sob pena de arcar com o pagamento da indenização no caso de insucesso.

E mais, verifica-se que a atitude da ré ao estipular a chamada "cláusula penal" muito se assemelha realmente a um contrato de seguro, em caso de roubo ou furto, de maneira que, aparentemente, a ré se utiliza da chamada cláusula penal - que mais parece um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

10ª Vara Cível

Rua dos Crisântemos, nº29, Guarulhos - SP - cep 07091-060

1015581-79.2022.8.26.0224 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1015581-79.2022.8.26.0224

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO

Requerente:

José Augusto Santana Souza

Requerido:

Persegue Consultoria Ltda

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lincoln Antônio Andrade de Moura

Vistos.

JOSÉ AUGUSTO SANTANA SOUZA, ingressou com ação de indenização por danos materiais e morais em face de PERSEQUE CONSULTORIA LTDA., alegando, em suma, que, no dia 22 de novembro de 2021, contratou junto a ré, um sistema para a prestação de serviços de rastreamento e monitoramento veicular, com o objetivo de ter rastreado seu motociclo da marca Honda, Modelo CG 160 FAN FLEX, Ano de fabricação 2021 e Ano de modelo 2022, placa FUZ0F67, Cor preta, em caso de eventual furto/roubo.

Narra que, na madrugada do dia 18 para o dia 19 de dezembro de 2021, entre às 02h00 e 05h00, sua motocicleta foi furtada enquanto todos da residência dormiam.

Assevera que, ao acordar pela manhã, o pai do autor ia à padaria, quando notou que a motocicleta não estava lá. Aduz que o cadeado da residência foi arrombado e a trava da moto teria sido cortada e, quando fora avisado por seu genitor, acionou a empresa ré para proceder no rastreamento e bloqueio do veículo, conforme contratado.

Alega que também registrou um boletim de ocorrência acerca dos fatos.

Sustenta, todavia, que a empresa não adotou todos os esforços para localizar a motocicleta do autor, mesmo possuindo a localização exata do motociclo e, após algum tempo, o aplicativo foi bloqueado pela empresa ré.

Narra que a empresa requerida não efetuou buscas em relação à motocicleta, por alegar ser um lugar "perigoso", qual seja o Jardim Fontális, São Paulo/SP e, como o

veículo não foi encontrado, em 30 dias foram encerradas as buscas.

Aduz que estava adimplente com o contrato por ocasião do infortúnio e enviou todos os documentos solicitados pelo requerido, exceto a CNH.

Sustenta que não chegou a realizar os testes mensais, posto que à época do furto ainda não tinha completado 1(um) mês de contrato com a empresa ré, não obstante, no momento da contratação, não foi informado de que a não realização dos testes desobrigaria a ré ao pagamento da cláusula penal.

Sustenta que inclusive teve que procurar um advogado, emitindo procuração a fim de que fosse retirada perante o DEIC, a certidão de não localização do veículo furtado, arcando com o custo de R\$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), porém a ré se recusou a efetuar o pagamento de indenização.

Afirma que faz jus ao recebimento do valor da indenização relativa ao bem furtado, no valor atual de R\$ 15.129,00 (quinze mil e cento e vinte e nove reais) de acordo com o seu valor pela tabela FIPE, bem como pelos prejuízos que vem sofrendo, uma vez que está desempregado desde janeiro de 2022 e pretendia trabalhar como motoboy, utilizando a motocicleta furtada para tal finalidade.

Alega que também teria sofrido danos morais, em virtude do ocorrido.

Assim, requereu:

a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos materiais, no valor de R\$ 20.000 (vinte mil reais) devidamente corrigidos;

a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no valor de R\$ 10.000 (dez mil reais);

a inversão do ônus da prova;

a gratuidade de justiça.

Instruíram a inicial, documentos de fls. 12/65.

Citada, a requerida apresentou contestação impugnando o pedido de gratuidade de justiça. Alega que o contrato de prestação de serviços de rastreamento e monitoramento celebrado entre as partes tem linguagem clara e de fácil compreensão, não podendo o requerente alegar desconhecimento dos serviços prestados, nem confundir-lo com contrato de seguro. Narra que suas obrigações se limitam à emissão de sinais de rastreio do bem e tentativa de localização do veículo, o que foi feito. Aduz que possui obrigação de meio e não de resultado.

Afirma que a "Cláusula Penal" prevista em contrato, não se confunde com indenização, vez que não é devida caso o bem não seja localizado, mas sim quando o bem não for localizado por não ter havido prestação do serviço, desde que o cliente entregue a documentação solicitada na cláusula 7.13 e não tenha descumprido suas obrigações. Discorreu acerca do funcionamento do serviço de rastreamento. Narra que é uma prestadora de serviço de rastreamento, razão pela qual conta com o Selo de Qualidade - ABESE (Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança). Alega que, assim que informada do furto, realizou buscas na região e localizou apenas o rastreador que havia sido retirado do motociclo. Afirma que o requerido descumpriu a cláusula contratual que determina que a informação de furto seja passada em 15 minutos, porém o autor apenas realizou a comunicação após mais de uma hora do ocorrido, o que dificulta os serviços da requerida. A lavratura do boletim de ocorrência também teria demorado a ser feita.

Sustenta que há indícios de simulação do furto, eis que o dispositivo de rastreamento é conectado à bateria do veículo, porém possui uma bateria reserva, no caso de ser desconectado, o que seria chamado de "violação da bateria". Afirma que o sistema registrou a "violação da bateria" a 9,3 km de distância do local do furto, horas antes da comunicação da comunicação à central de atendimento. O autor não possuía CNH, o que implica em infração ao CTB e perda da indenização. Descabida a inversão do ônus da prova. O requerente contratou advogado por mera liberalidade. Ademais, o valor constante da cláusula penal é de R\$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais), sendo descabido o valor pleiteado pelo requerente. Por outro lado, afirma que o contrato não fora quitado pelo requerente, restando oito parcelas em aberto, as quais devem ser descontadas da cláusula penal, em caso de eventual condenação. Inexistem danos morais.

Réplica a fls.184 e seguintes.

Instados a especificarem provas, o autor requereu seu próprio depoimento pessoal e oitiva de testemunha para comprovar o horário do furto, enquanto a ré não se manifestou.

É o relatório.

Decido.

O feito comporta JULGAMENTO ANTECIPADO nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, posto que a matéria em debate é exclusivamente de direito, despicienda dilação probatória.

I - DA IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

A assertiva de pobreza, para fins jurídicos, goza de presunção relativa ("juris tantum").

Para a revogação do benefício cabe à parte contrária elidir tal presunção. Contudo, a impugnante não se desincumbiu do ônus de provar a capacidade econômica do impugnado.

As argumentações aventadas nesta impugnação não tem o condão de afastar o benefício concedido.

Destarte, além da presunção relativa de que goza a afirmação de pobreza, os documentos juntados são suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do autor para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, mais honorários advocatícios.

O pedido de assistência judiciária gratuita foi minuciosamente analisado pelo Juízo.

Consoante artigo 98 do Novo Código de Processo Civil, será considerado necessitado para os fins legais, aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas e honorários advocatícios.

Deveria a impugnante comprovar que a situação financeira do autor é suficiente para que o pagamento das custas processuais não afete sua subsistência. No mundo do direito, somente é concreto o que se pode ser comprovado, alegações vãs, não podem servir de fundamento para ser afastado um benefício, que protege o direito constitucional do cidadão de ingressar em Juízo.

Pois este é o princípio lastreador da assistência judiciária gratuita, proporcionar aos menos favorecidos o acesso à Justiça, concedendo o não pagamento das custas e despesas.

Por outro lado, a contratação de advogado particular de sua confiança não impede a parte de receber os benefícios da assistência judiciária.

A constituição do patrono, não induz a suficiência financeira. A parte não é obrigada a recorrer aos serviços prestados pelo convênio PAJ/OAB para ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA C/ C INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO PELA AUTORA - ADMISSIBILIDADE. "O simples fato do agravante se encontrar representado por advogado não se reflete em óbice à outorga do benefício, conforme a melhor exegese da legislação pertinente". Provimento do recurso. (Relator(a): Francisco Thomaz; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 29ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 24/06/2015; Data de registro: 26/06/2015)

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - Condição única para concessão: necessidade - Parte representada por advogado particular - Irrelevância - Fundamento afastado.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA - A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum, que pode ou não ser confirmada por elementos existentes no processo, a autorizar o Juízo a indeferir a concessão do benefício - Presunção de necessidade presente - Hipótese em que o interessado apresenta holerite revelando rendimentos pouco superiores a quatro salários mínimos, adquiriu apartamento de pequenas dimensões e arca com prestações de financiamento e demais encargos - Inexistência de elementos

a elidir a presunção de necessidade – Benefício da gratuidade negado, decisão reformada. Agravo provido. (Relator(a): João Carlos Saletti; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 26/05/2015; Data de registro: 25/06/2015) Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 26/05/2015; Data de registro: 25/06/2015) Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 26/05/2015; Data de registro: 25/06/2015)

Ressalta-se também que miserabilidade não é pressuposto para obter o benefício. Nesse sentido:

Basta a declaração de pobreza para a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Presunção só ilidida por eventual prova feita pela parte contrária, que, todavia, não foi produzida. Recepção do artigo 4º da lei 1060/50 pela Constituição Federal. Miserabilidade que não é condição para a obtenção do benefício. Agravo provido. (Relator(a): Soares Levada; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 17/06/2015; Data de registro: 19/06/2015)

Assim, não tendo a impugnante comprovado a possibilidade financeira do impugnado em arcar com os custos e despesas processuais, bem como verba honorária, de rigor o não acolhimento desta impugnação.

Dessa forma, REJEITO a presente impugnação ao pedido de assistência judiciária gratuita, mantendo-se o benefício ao autor.

II - DA RELAÇÃO DE CONSUMO

Cumpré, em seguida, observar que a relação jurídica entre as partes se enquadra na definição de relação de consumo.

Para que seja amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, deve possuir relação negocial, que visa a transação de produtos ou serviços, feita entre consumidor e fornecedor.

Consumidor, como definido pelo art. 2º do Código de Defesa do Consumidor, é toda a pessoa física ou jurídica que adquire um bem ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final.

Por outro lado, fornecedor é aquele que desenvolve atividade de produção, montagem, criação, exportação, distribuição ou comercializa produtos ou serviços, podendo ser qualquer pessoa física, jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira e até entes despersonalizados, nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, a relação jurídica entre o requerente e a requerida se enquadra perfeitamente nas condições de relação de consumo, pois entre elas houve um nexo de causalidade, capaz de obrigar uma a entregar uma prestação à outra.

Portanto, rege a relação material o Código de Defesa do Consumidor.

Neste diapasão, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, para facilitação do direito de defesa do consumidor, nos termos do inciso VIII, artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, ante a verossimilhança das alegações iniciais e ainda da hipossuficiência técnica e financeira do autor perante a ré.

III - DO MÉRITO

Restou incontroverso nos autos a celebração de contrato de prestação de serviços entre as partes, referente ao serviço de rastreamento/monitoramento do veículo descrito na peça vestibular (fls. 30/44).

Sustenta o autor, em sua inicial, que teria tido seu veículo furtado de dentro da garagem de sua residência, na madrugada do dia 19 de dezembro de 2021, ocasião em que registrou um boletim de ocorrência acerca dos fatos e comunicou à requerida o ocorrido.

A ré, por sua vez, nega seu dever de indenizar, sob o argumento de que não é seguradora, possuindo obrigação apenas de meio de não de resultado e, na hipótese dos autos, a indenização não seria devida, porque o autor teria descumprido as cláusulas contratuais, especialmente em relação ao tempo de comunicação do sinistro à ré e a autoridade policial, ausência de CNH, bem como suspeita de simulação do

furto, por ter havido “violação da bateria” horas antes da comunicação do sinistro. Pois bem.

Verifica-se que o contrato celebrado entre as partes possui a denominada “cláusula penal”, no valor de R\$ 13.400,00 (fls. 32).

Consoante se extrai das cláusulas 7.7 e 7.8 do contrato firmado:

“ (...) 7.7. Caso o Veículo não seja localizado em até 30 (trinta) dias, contados da comunicação da ocorrência de furto ou roubo à Central de Atendimento, as Partes acordam que o CONTRATANTE deverá entregar toda a documentação constante na cláusula 7.13 do presente contrato, comprovando atender as exigências deste contrato para análise.

7.8. Desde que cumpridas todas as exigências contratuais pelo CONTRATANTE será devido pela CONTRATADA o valor especificado em cláusula penal descrito no preâmbulo deste contrato, ainda que superior seja o valor do veículo, declarando o CONTRATANTE, desde já, estar ciente que não receberá qualquer valor superior ao fixado no contrato, para nada mais reclamar a justo título.(...)”

Desta maneira, verifica-se que o contrato prevê que, caso o veículo fosse roubado/furtado e não localizado dentro do prazo de 30 dias, contados da comunicação do roubo ou furto, seria devido pela contratada o valor previsto na cláusula penal estipulada, desde que observadas as obrigações do contratante, de acordo com o disposto nas cláusulas do aludido contrato.

Nesse contexto, o primeiro detalhe que chama a atenção é que, embora a requerida alegue que sua obrigação é de meio e não de resultado, como inclusive consta na cláusula 1.13, fls. 34, tal informação não é verdadeira, na medida em que a própria ré se pune, caso não obtenha êxito na localização do veículo.

Se é assim, não há como acolher a tese de que o contrato seria apenas de meio, como alegado, já que a requerida assumiu a responsabilidade de localizar o veículo, em caso de roubo ou furto, sob pena de arcar com o pagamento da indenização no caso de insucesso.

E mais, verifica-se que a atitude da ré ao estipular a chamada “cláusula penal” muito se assemelha realmente a um contrato de seguro, em caso de roubo ou furto, de maneira que, aparentemente, a ré se utiliza da chamada cláusula penal - que mais parece um seguro-, para atrair seus clientes prometendo sim o êxito na localização do bem objeto do contrato, ou o pagamento de indenização, caso não o localize.

Note-se, ainda, que é feito um cálculo de risco, mediante o preenchimento de um questionário pelo contratante (fls. 47/48), e a requerida condiciona o pagamento da indenização ao repasse dos direitos sobre o automóvel pelo contratante (cláusula 7.13, M), logo, a requerida age tal qual uma seguradora faria.

O problema está no fato de que a atividade das seguradoras é regulamentada pela Susep, de maneira que a primeira providência a ser adotada é a extração de cópia integral destes autos e remessa à Susep e ao Procon, para apuração de prática empresarial pela requerida, sem que haja a devida autorização dos órgãos competentes para tanto.

Em seguida, observo que, na hipótese dos autos, o veículo não fora recuperado, sendo necessário analisar se o autor realmente teria infringido as cláusulas contratuais a ponto de perder o direito ao recebimento da indenização respectiva.

A primeira alegação da ré é que o autor teria demorado cerca de 1h14min para comunicá-la acerca do furto e, cerca de 31 minutos para registrar o boletim de ocorrência, após comunicar os fatos à ré.

Consta da inicial, que o veículo do autor teria sido furtado de dentro de residência durante a madrugada, sendo o furto constatado pelo genitor do autor e comunicado a ré cerca de 30 minutos após a ciência do ocorrido e lavrado o boletim de ocorrência por volta das 7h29min do dia 19 de dezembro de 2021 (ver fls. 02/03, último e primeiro parágrafos).

Em réplica, o autor esclareceu, todavia, que seu pai o teria comunicado acerca do ocorrido por volta das 5h40 min e o autor teria entrado em contato com a ré por volta das 5h47min, de maneira que a comunicação à ré, em verdade, teria sido realizada dentro do prazo estipulado em contrato e a lavratura do boletim de

ocorrência teria ultrapassado em apenas 8 minutos o prazo estipulado contratualmente.

Na carta de próprio punho de fls. 53, também consta que o autor teria tido ciência do furto por volta das 5h40 da manhã do dia 19/12/2021.

Pois bem.

Pelo que se extrai dos autos, a comunicação à ré teria ocorrido às 5h47min, conforme fls. 84, ao passo que o boletim de ocorrência acerca dos fatos, por seu turno, foi registrado no dia 19/12/2021 às 06h18min, tal como se observa a fls. 51/52.

Assim, verifica-se que, em verdade, o autor teria efetuado a comunicação do sinistro a ré dentro do prazo estipulado em contrato, e teria excedido o prazo previsto para comunicação à autoridade policial em apenas 8 minutos.

Com efeito, a cláusula contratual 7.16, fls. 41 prevê o prazo de 15 minutos para comunicação do fato à ré e 30 minutos para que haja comunicação junto às autoridades policiais.

Necessário destacar que as cláusulas não podem ser interpretadas em desfavor do consumidor, e o contratante apenas poderá efetuar a comunicação à ré a partir do momento em que ele tomar ciência que o objeto foi subtraído.

Considerar de forma contrária significaria incluir uma cláusula cuja onerosidade seria de tal forma prejudicial ao consumidor que seria reputada inclusive inválida.

Na hipótese dos autos, compreendo que o intervalo de tempo transcorrido entre a ciência dos fatos e a comunicação autoridade policial (38 minutos) não fora longo o suficiente para causar a perda do direito à indenização respectiva, notadamente porque a ré já havia sido comunicada dentro do prazo de quinze minutos mencionado. No que tange à ausência de CNH, compreendo que a alegação também deve ser rechaçada, a uma porque o veículo estava estacionado no momento do furto e, a duas, porque a ausência de CNH em nome do contratante não foi obstáculo à contratação do serviço de rastreamento oferecido pela requerida, de maneira que se mostra descabido que seja utilizado pela ré como óbice ao pagamento da indenização respectiva.

Por fim, no que tange à alegação de suposta simulação do furto, observo que o autor informou que o veículo teria sido furtado de sua residência, durante a madrugada, de maneira que apenas tomou ciência dos fatos ao acordar pela manhã.

De acordo como documento de fls. 90/91, o dispositivo de rastreamento teria sido desconectado da bateria do motociclo, por volta das 05h12min do dia 19 de dezembro de 2021 na Rua Kotinga, 1912, Vila Nova Curuçã, São Paulo/SP, enquanto o autor reside na Rua Edgar, nº 143 - casa 6, Jardim Diogo, Guarulhos/SP.

Em consulta em relação à rota entre os dois endereços no site Google Maps, verifica-se que o trajeto demoraria cerca de 30 minutos com base nos dados de longitude e latitude informados pela ré (fls. 90/91), conforme consulta realizada por mim na data de hoje às 17h13min, por meio do link:

<https://www.google.com.br/maps/dir/R.+Edgard,+143+-+casa+6+-+Jardim+Diogo,+Guarulhos+-+SP,+07124-380/-23.42279+-46.5817/@-23.4330881,-46.5748193,14z/data=!3m1!4b1!4m12!4m11!1m5!1m1!1s0x94cef4d95943acc9:0xd1d562480e546f74!2m2!1d-46.5298675!2d-23.431294!1m3!2m2!1d-46.5817!2d-23.42279!3e0>.

Desta maneira, se o motociclo fora furtado em horário incerto, durante a madrugada, então o próprio furtador teria tido tempo suficiente para se deslocar entre os dois pontos e efetuar a remoção do aparelho rastreador, que fora posteriormente localizado pela ré (fls. 179).

Assim, entendo que o autor faz jus ao recebimento do valor de indenização prevista na cláusula penal, no importe de R\$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais).

Não há como acolher o valor indicado na peça vestibular, eis que deve ser observado o valor avençado entre as partes no respectivo contrato.

Contudo, o autor não impugnou o fato de que não teria adimplido oito parcelas após a ocorrência do furto, de maneira que de rigor que os valores em aberto sejam descontados do valor da indenização respectiva, sob pena de enriquecimento ilícito do demandante.

Os pedidos relativos à contratação de advogado para emissão da certidão de não localização do veículo e supostos lucros cessantes, todavia, não poderão ser

acolhidos.

Com relação ao pedido de condenação da ré ao ressarcimento do valor gasto com contratação de advogado para obtenção de certidão junto ao DEIC, verifico que o autor poderia ter obtido a certidão por seus próprios meios, porém optou por contratar advogado, a sua livre escolha. Firmou o contrato referente aos honorários por sua livre vontade, assim, obviamente deverá arcar com o pagamento.

Ademais, os lucros cessantes são definidos como aquilo que, razoavelmente deixou-se de lucrar em razão direta e imediata do ilícito praticado, conforme disposição dos artigos 402 e 403 do Código Civil, ou seja, refere-se ao quanto auferiria.

Na hipótese dos autos, havia somente expectativa futura de ganho, sem concretude alguma, já que o autor fundamentou seu pedido tão somente no que ele teria deixado de ganhar, caso hipoteticamente tivesse utilizado a motocicleta para fazer entregas a partir de janeiro de 2022.

Assim, mera expectativa de ganho, não pode ser reparada por lucros cessantes.

IV - DOS DANOS MORAIS

No mais, o pedido de indenização por dano moral não comporta acolhida, tendo em vista que se compreende o dano moral como séria ofensa a direito de personalidade que produza efeitos extrapatrimoniais, o que não se verifica nos autos.

Não é demais recordar que este juízo compreende não existir o aludido caráter punitivo no valor das indenizações a serem fixadas, em que pese o teor do Enunciado n. 379 do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal.

De fato, a finalidade da análise da culpa no dimensionamento da indenização é, em suma, proporcionar uma sanção (pena) adequada ao agente do causador do dano respectivo.

Ocorre que, conforme a nossa posição, o conceito de indenização por dano moral não prevê a aplicação de pena, coisa esta, portanto, que lhe seria algo distinto.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, incisos V e X, apenas prevê a possibilidade de indenização pelo dano moral decorrente de sua violação. Não há em sua redação nenhuma referência a alguma sinonímia entre indenização e punição.

Ao contrário: quando a Constituição passou a se referir sobre a imposição de pena, fez por meio de outro inciso.

O art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal dispõe que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal, assim, para que ocorra a imposição da pena, deverá existir lei expressa que a preveja.

Note-se que o texto constitucional não fez distinção entre pena, para os fins da lei civil, e pena, para os fins da lei criminal.

Tal como ocorre do direito penal, quando, na lei civil, houve a intenção de aplicar sanção ao agente causador do ilícito civil, sobreveio a descrição da conduta proibida, com a consequente imposição da pena aplicável.

Tome-se, por exemplo, o art. 940 do Código Civil, cuja redação respeita os parâmetros supramencionados, na medida em que prevê a conduta proibida (aquele de demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do que for devido,...), bem como prevê a sanção respectiva (...ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro que houver cobrado e, no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição).

Note-se que redação semelhante ocorre com o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.

Veja-se, ademais, o exemplo exposto no art. 883 do Código Civil, em que a conduta proibida (aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral ou proibido por lei) sofrerá a sanção correspondente (não terá direito à repetição e o que se deu reverterá em favor de estabelecimento local de beneficência, a critério do juiz).

Ocorre que, para a hipótese de indenização, não há previsão de pena, seja pela omissão constitucional, sejam pela emissão do texto legal.

Assim, o Código Civil, ao disciplinar o tema referente ao valor indenizatório, determinou que este será medido conforme a extensão do dano (art. 944 do Código Civil).

Aqui se faz necessário destacar que a redação do art. 944 do Código Civil não faz distinção entre dano moral e material justamente para não contrariar as disposições constitucionais.

Por outro lado, não há previsão legal para chamado punitive damages (conforme o direito norte-americano).

De fato, a redação do art. 5, incisos V e X, ambos da Constituição Federal, bem como a redação do art. 944 do Código Civil, mais se assemelham ao texto do § 249 do Código Civil Alemão, cuja redação apenas prevê a hipótese de indenização, afastada a possibilidade de se levar em consideração, na fixação da indenização por dano moral, o suscitado aspecto punitivo.

Anderson Schreiber acrescenta ainda outros dois argumentos contrários ao entendimento resumido pelo teor do Enunciado do 379 do CEJ:

- a) haveria enriquecimento sem causa;
- b) se fosse de caráter punitivo, não se admitiria a transferência da responsabilidade a terceiro.

('Novos Paradigmas da Responsabilidade Civil - Da Erosão dos Filtros da Reparação à Diluição dos Danos', 2006, Editora Jurídico Atlas, página 219).

A hipótese em comento versa sobre o simples descumprimento contratual, não se verificando maior dano ao autor a ponto de ensejar a indenização pretendida.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. (...) 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar conteúdo contratual (Súmula 5/STJ), bem como matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. O mero descumprimento contratual não acarreta dano moral indenizável. 3. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 4. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Enunciado 182 da Súmula do STJ). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1562193/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 17/06/2016)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMÓVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ENTREGA. ATRASO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. 1. Esta Corte tem firmado o posicionamento de que o mero descumprimento contratual, caso em que a promitente vendedora deixa de entregar o imóvel no prazo contratual injustificadamente, embora possa ensejar reparação por danos materiais, não acarreta, por si só, danos morais. 2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 570.086/PE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 27/10/2015)

Assim, sem demonstração de maiores prejuízos ao autor, não há como acolher o pleito indenizatório.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, o que faço para CONDENAR a ré ao pagamento do valor previsto na denominada cláusula penal do contrato celebrado entre as partes, no importe de R\$ 13.400,00 (treze mil e quatrocentos reais), devendo ser descontado do valor da condenação, todavia, o valor relativo às oito parcelas que teriam sido deixadas em aberto pelo autor. Vislumbro sucumbência recíproca, então arcarão as partes com o pagamento das custas e despesas processuais na proporção de 2/3 para o autor e 1/3 para a ré, bem como verba honorária advocatícia que fixo em 10% do valor da condenação para cada parte, observada a gratuidade.

Extraia-se cópia integral destes autos e providencie-se a remessa à Susep e ao Procon, para apuração de prática empresarial pela requerida sem que haja a devida autorização dos órgãos competentes para tanto, expedindo-se o necessário.

Valerá esta sentença como ofício a ser instruído e encaminhado pela z. Serventia. P.I.C.

Guarulhos, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA